

1502044-77.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1502044-77.2019.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502044-77.2019.8.26.0542

Controle: 2019/002327

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Suelen Gomes da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

SUELEN GOMES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 23 de julho de 2019, por volta das 11h, na Rua Cuiabá, Viela 3, Rochdalle, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, trazia consigo: 27 trouxinhas contendo 69,06g de maconha, 50 invólucros plásticos contendo 15,5g de crack, e 22 eppendorfs contendo 18,13g de cocaína, todas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, policiais civis patrulhavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de traficância, quando se depararam com Suelen e Rafael Vieira, ambos em atitude típica da mercancia ilícita, razão pela qual procederam a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Rafael. Todavia, na sacola que Suelen trazia nas mãos, foram localizadas as porções de drogas.

Indagados, Suelen prontamente, informalmente, confirmou que estava no local comercializando o entorpecente, ao passo que Rafael afirmou que estava ali para comprar droga dela.

A denúncia foi ofertada e notificada Suelen (fls. 111). Sobreveio a defesa

preliminar (fls. 118/120) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2019 (fls. 126/127). Suelen foi citada (fls. 229). Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 237/238), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 239).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 240).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Suelen nos termos da denúncia (fls.

243/248).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, conforme artigo 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 252/267).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação prévia (fls. 12/20), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 237/238).

Perante a D. Autoridade Policial, Suelen afirmou morar na favela local do ocorrido e ser usuário de cocaína. Estava comercializando drogas para sustentar seu consumo (fls. 6).

A confissão extrajudicial da autoria, como é cediço, vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela contém (RT 95/563). É mister emprestar-lhe a necessária credibilidade, vez que vem corroborada pelas demais provas amealhadas aos autos. Neste sentido:

“Em regra, a prova constante do inquérito policial não deve ser desprezada, mormente em caso em que o delito ocorre sob a clandestinidade, como o furto. As confissões nele obtidas regularmente estando seus termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos, têm valor probante e podem ser aceitas, se não elididas na fase judicial” (TACRIM/SP - Acrim 22.508).

Em Juízo, negou a prática delitiva. Declarou que é usuária de drogas e foi comprar entorpecente com esse rapaz que estava vendendo. Os policiais fizeram a abordagem e era ele que estava com a sacola nas mãos. Sentou-se ao lado dele porque estava passando mal. O segundo policial que prestou depoimento ainda lhe deu três socos no estômago. Na Delegacia, foram separados. Assinou o depoimento na Delegacia, mas não leu o que estava escrito. Quando foi levada ao I.M.L. perguntou ao policial onde estava o rapaz que estava preso. O policial respondeu que tinha sido preso. Na audiência de custódia soube pelo defensor que tinha assinado tráfico e que Rafael lhe denunciou (fls. 239).

A negativa de Suelen, na fase judicial, não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado, desmerecendo, portanto, guarida.

A testemunha Policial Civil Daniel se recordou dos fatos porque leu o B.O.. Pôde informar vagamente que havia constantes denúncias de tráfico de drogas no local. Avistaram Suelen conversando com outro rapaz. Ela tinha sacola nas mãos que continha drogas. O rapaz foi levado como testemunha.

Não se lembrou o que foi dito pela acusada em relação às drogas.

Recordou-se que a acusada tinha uma pequena distorção nos olhos, mas atualmente ela estava diferente. Ela não tentou se desvencilhar da sacola quando da aproximação dos policiais. A sacola era um saco plástico (fls. 237).

A testemunha Policial Civil André asseverou que leu o B.O. para se relembrar dos fatos. Pelo histórico a acusada estava acompanhada de um rapaz em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecente e onde fizeram outros flagrantes. Ela estava com uma sacola com maconha, cocaína, crack e um celular.

Não se recordou o que foi dito pela acusada a respeito. Não se lembrou o que foi dito pelo rapaz também.

Não se recordou se havia outras pessoas próximas. Não presenciou ato de venda. Não se recordou se ela tentou se desvencilhar da sacola antes da aproximação dos

policiais. Não se lembrou as características da sacola. Recordou-se da acusada como sendo a pessoa que foi abordada (fls. 238).

Os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto no aspecto principal, sendo irrelevante a leitura de anotações. Outrossim, corroboradas pela confissão extrajudicial de Suelen.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Suelen. Ela foi abordada em conhecido ponto de traficância, sendo que, quando os agentes policiais se aproximaram, avistaram-na com um saco plástico em mãos. Suelen estava com Rafael. Em revista, com ele, nada de ilícito foi encontrado. Já no saco plástico que Suelen tinha em mãos foi encontrado o entorpecente. Informalmente, ela confirmou a traficância e, na fase inquisitorial, também, dizendo ser drogada em cocaína e que traficava para ter entorpecente para seu uso.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Suelen foi denunciada por trazer consigo substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de

terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a condição de usuário não exclui a traficância. Vale ressaltar que Suelen narrou ser dependente de cocaína, entretanto, com ela foram encontradas, além de cocaína, crack e maconha. Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Suelen por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus às atenuantes do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso extrajudicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundido-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É primária e não ostenta maus-antecedentes criminais.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM

CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elege-se dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente primário, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À mingua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto. Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo

nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO SUELEN GOMES DA SILVA, qualificada nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo, por incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 05 de dezembro de 2022.